

1501782-82.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... Ele confessou informalmente o tráfico e disse que vendia as drogas para pagar uma dívida. Não conhecia o acusado antes dos fatos. O local é conhecido como ponto de tráfico. O réu, em interrogatório, declarou que trabalha como servente. Dois dias antes dos fatos, sofreu um acidente com sua moto. Por conta disso, no dia do ocorrido, acordou com dor e, como estava chovendo, seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501782-82.2021.8.26.0599 - Controle nº 2021/001304

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315523/2021 - 02º D.P.

PIRACICABA, 21488569 - 02º D.P. PIRACICABA, 4503/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2315523 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS

Réu Preso

Aos 24 de maio de 2022, às 13:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PM WANDERSON ELIAS RAMOS DA COSTA AZEVEDO

Testemunha comum: PM HELIO PEREIRA NOGUEIRA - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha PM WANDERSON ELIAS RAMOS DA COSTA AZEVEDO.

Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, por ele foi dito que desistia da oitiva da testemunha PM HELIO PEREIRA NOGUEIRA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PM

HELIO PEREIRA NOGUEIRA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.
Após, o réu MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 112/114. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 138), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 145/149), sendo a denúncia recebida (fls. 150/152). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, fotografia de fls. 17 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 129/131. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial militar Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu conduzindo uma bicicleta, subindo a rua, portando uma pochete. Disse que, ao visualizar a guarnição, o acusado mudou a direção, em atitude suspeita, adentrando em um bar existente na localidade. Relatou que acompanharam o descolamento do réu, o qual foi encontrado no interior do banheiro do bar, e durante a abordagem, localizaram a pochete com o réu, no interior da qual havia 20 pedras de "crack" e 68 eppendorfs de cocaína em pó. Questionado, o acusado alegou que estava traficando nas imediações para pagar uma dívida e que o dinheiro era proveniente da venda de um micro tubo de cocaína. Por fim, o policial informou que o local em que o acusado estava já era bastante conhecido como sendo ponto de venda de drogas. No mesmo sentido foram as palavras do policial militar Hélio Pereira Nogueira, ouvido apenas na fase policial. Por fim, interrogado, o réu negou os fatos a si atribuídos, alegando que saiu de sua casa com dez reais para ir ao mercado e, no local dos fatos, que realmente é ponto de venda de drogas, encontrou dois "moleques", com os quais parou para conversar. Disse que neste momento foram abordados pelos policiais, que chegaram no local e começaram a procurar drogas pelas redondezas. Disse que viu um policial abaixar na calçada perto de uma calha e dali pegar algo, tendo então sido colocado na viatura e levado até a delegacia. Confirmou que estava de bicicleta e negou que estivesse com uma pochete, a qual acredita que estivesse com um dos moleques. Entretanto, sua versão não tem como prevalecer, eis que restou totalmente isolada no álbum probatório. Alias, insta ressaltar que a versão apresentada pelo acusado em Juízo diverge inclusive do por ele próprio alegado em sede policial, quando foi detido em flagrante. De fato, na ocasião, perante a autoridade policial, o acusado alegou que estava subindo a rua de bicicleta e foi "enquadrado" pelos policiais militares, ao quais, em revista pessoal, encontraram em seu poder a pochete, telefone e documentos. Narrou que sua genitora apareceu naquele momento e os policiais entregaram diretamente para ela o celular, corrente e pulseira. Afirmou, ainda, que os policiais encontraram drogas próximo ao local da abordagem, no pé de uma árvore, e não em uma calha ou cano, com alegou em Juízo. Assim, em que pese a negativa do réu quanto aos fatos, sua versão não deve prevalecer, vez que dissonantes e isoladas das demais provas coligidas nos autos, não encontrando nelas qualquer respaldo. De fato, insta ressaltar que o policial militar ouvido foi categórico ao afirmar que o acusado estava em local conhecido como ponto de venda de drogas, demonstrou conduta suspeita ao avistar a viatura policial e em seu poder foi encontrada uma pochete contendo os entorpecentes apreendidos e uma quantia em dinheiro, a qual o próprio acusado confessou informalmente e que era proveniente de venda de drogas anterior, tendo

ele confessado a mercancia ilícita perante os milicianos. Por outro lado, insta consignar que os depoimentos prestados pelos policiais são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, verifica-se que as circunstâncias judiciais são neutras. Na segunda fase, observa-se que o réu é multireincidente (autos nº 0009863-76.2020 - fls. 115/116; 1500019-28.2020 - fls. 116; 1503200-37.2020 - fls. 116; e 1503840-70.2019 - fls. 118/119). Na terceira fase, ante a multireincidentia, inaplicável o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Requeiro, por fim, seja decretado o perdimento do valor apreendido com o acusado, consistente em R\$ 10,00 (dez reais), com fulcro nos artigos 61 e 63, ambos da Lei nº 11.343/2006. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordia".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordia. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado, razão pela qual deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Wanderson, Policial Militar, declarou que estavam em patrulhamento pelo bairro quando, ao ingressarem no local descrito na denúncia, avistaram o réu. Ao ver a viatura, ele tentou se evadir e ingressou em um bar. Entraram no bar e abordaram o acusado no banheiro. Em revista pessoal, encontraram uma pochete contendo as drogas descritas na denúncia e a quantia de R\$ 10,00. Ele confessou informalmente o tráfico e disse que vendia as drogas para pagar uma dívida. Não conhecia o acusado antes dos fatos. O local é conhecido como ponto de tráfico. O réu, em interrogatório, declarou que trabalha como servente. Dois dias antes dos fatos, sofreu um acidente com sua moto. Por conta disso, no dia do ocorrido, acordou com dor e, como estava chovendo, seu patrão pediu para não ir trabalhar. Diante disso, pegou R\$ 10,00 e foi comprar produtos no mercado para tomar café da manhã. Por conta disso, passou pelo local, que é ponto de tráfico. Lá, encontrou um amigo e um outro menino que estava com ele, que não conhecia. A Polícia chegou e o abordou, assim como aos outros meninos. Um dos Policiais começou a fazer uma busca pelos arredores e até abaixou em um buraco. Depois, eles conversaram entre si e chamaram outra viatura. Foi colocado na viatura e os outros meninos foram liberados. Nem sabia o motivo pelo qual estava sendo preso. Viu apenas um Policial abaixando em uma calçada e olhando no buraco de um cano, mas não sabe se ele achou a droga no local. Estava de bicicleta, porém, o local é utilizado para sua passagem para ir trabalhar e ir ao mercado. Não estava com pochete. Acha

que ela pertencia a algum dos meninos que estava no local. Estava com celular, mas acha que os Policiais não o apreenderam. Já foi abordado pelos Policiais em uma outra ocasião, mas foi uma abordagem de rotina. Nunca esteve em Franca e nunca saiu de Piracicaba. Portanto, Excelência, o acusado nega a prática dos fatos. Sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais provas dos autos. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Policiais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem em Juízo a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras de Policiais ou outros agentes de segurança como fundamento para uma condenação: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se, pelo próprio depoimento dos Policiais, que nenhum "ato de comércio" foi visualizado antes da abordagem e não foram apresentados outros indivíduos na Delegacia de Polícia como testemunhas presenciais dos fatos e/ou como possíveis usuários das substâncias entorpecentes. Além disso, a mera afirmação de que o local dos fatos seria um "ponto de tráfico" não é presunção absoluta de dedicação do réu ao comércio de entorpecentes, eis que, nesses locais, também circulam usuários dessas substâncias. Ressalte-se, ainda, que a suposta confissão informal do acusado, além de constituir uma circunstância aberrante no ordenamento jurídico, não foi confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, se rejeitados todos os argumentos anteriores, verifica-se que, diante das declarações dos Policiais Militares, no sentido de que o acusado estaria comercializando os entorpecentes com o objetivo de quitar uma dívida contraída com outros traficantes, deverá ocorrer, então, a ABSOLVIÇÃO EM FUNÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. Excelência, vê-se, portanto, que não há reprovabilidade no caso em exame, pois na situação em que o acusado se achava não lhe era exigível comportamento diverso, haja vista ser fato público e notório que, muitas vezes, as pessoas que contraem dívidas com outros traficantes de drogas são obrigadas a auxiliarem na venda de entorpecentes para saldarem os débitos, sob pena de sofrerem graves represálias. Portanto, não

lhe era exigível conduta diversa por parte do direito penal, já que ele não tinha escolha razoável à disposição. Neste sentido, em não sendo possível praticar conduta diversa, recai sobre o caso uma excludente de culpabilidade. Ora, no desespero em que o acusado se encontrava, não viu outra saída senão vender as drogas, com a finalidade de garantir a sua integridade física. Caracterizada está, portanto, a inexigibilidade de conduta diversa, causa de exclusão da culpabilidade, conforme entendimento doutrinário, sendo necessária a absolvição. Todavia, caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, MESMO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerado reincidente, vale lembrar que a Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminosa), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFE, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao seu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição (“O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos”, in Direitos Humanos – Visões Contemporâneas, edição de Associação Juizes para a Democracia, 2001). Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase,

a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência; (ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea (ainda que informal), compensando-a com eventual agravante da reincidência, diante do caráter subjetivo e preponderante de ambas as circunstâncias. Além disso, na segunda fase, diante das inconsistências verificadas nos processos relativos à Comarca de Franca/SP (os quais, inclusive, embora constem da Certidão de Objeto e Pé, não estão mencionados na Folha de Antecedentes do réu – fls. 123/128), requer-se a este E. Juízo que desconsidere os referidos processos como maus antecedentes ou reincidência; (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iii) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ e, ainda, em razão do disposto no art. 387, § 2º, do CPP; (iv) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06 porque, segundo a denúncia, no dia 19 de novembro de 2021, por volta das 11h00, na Rua Neusa Maria Mendes Tonin, nº 1304, bairro Água Branca, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 20 (vinte) porções de cocaína na forma de crack, pesando cerca de 2,9g (dois gramas e nove decigramas), e 68 (sessenta e oito) eppendorfs de cocaína em pó, com peso líquido de 21,4g (vinte e um gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares estavam em regular patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram o réu conduzindo uma bicicleta na via pública e portando uma pochete. Ao visualizar a viatura, o réu mudou a direção que seguia e entrou em um bar situado nas proximidades. Em razão disso, os agentes públicos adentraram o bar e abordaram o réu no interior do banheiro do estabelecimento. Em busca pessoal, especificamente na pochete que o réu trazia consigo, os milicianos apreenderam os entorpecentes retro descritos e a quantia de R\$ 10,00 em espécie. Indagado, o réu admitiu que estava traficando nas imediações para pagar uma dívida e que o dinheiro localizado em sua posse era proveniente da venda de um eppendorfs de cocaína.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 138) e apresentou defesa preliminar (fls. 145/149), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia em 21.03.2022 (fls. 150/152).

Designada audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia e interrogado a réu.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pela fotografia de fls. 17 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 129/131 que trouxe resultado positivo para cocaína.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu negou a prática do delito. Disse que estava subindo a rua de bike e foi "enquadrado" pelos policiais militares, que encontraram na sua posse somente a pochete, o telefone e documentos.

Asseverou que os policiais localizaram as drogas nas proximidades, no pé de uma árvore. Alegou que a droga apresentada não lhe pertencia (fls. 04). Em juízo, voltou a negar a prática do crime, mas inovou. Declarou que, dois dias antes dos fatos, sofreu um acidente de moto e ficou com braço e perna ralados. Afirmou que estava conseguindo trabalhar normal, mas, no dia dos fatos, estava chovendo, razão pela qual tomou um remédio e voltou a dormir. Posteriormente, saiu de casa com R\$ 10,00 para ir ao mercado. Alegou que estava de bicicleta e passou pelo local dos fatos, que reconhece ser ponto de tráfico. Disse que, no local, estavam dois moleques e um deles, que já conhecia, o chamou para conversar. Alegou que, logo depois, os policiais chegaram e os abordaram. Atestou que eles perguntaram quem tinha passagem e um dos policiais vasculhou o local, procurando drogas e se abaixou perto do cano de uma calçada. Declarou que foi colocado na viatura e os outros dois moleques foram liberados. Aduziu que não estava com pochete, mas viu uma na Delegacia, que não lhe pertencia. A duplicidade de versões retira a credibilidade da palavra do réu, posto que essa situação não é compatível com a de quem pode explicar adequadamente os fatos. A cada momento em que deu sua versão dos fatos, contou uma história diferente, o que reflete negativamente em sua situação, pois caso fosse realmente inocente, não teria necessidade de ofertar versões diferentes a cada vez que fosse ouvido (cf. Apelação 0004859-04.2005.8.26.0481, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12.06.12).

De outro lado, a prova produzida é maciça e incriminadora.

O policial militar Wanderson relatou que estavam em patrulhamento pelo bairro Oriente e avistaram o réu, que, ao notar a viatura, tentou se evadir e entrar num bar, onde correu direto para o banheiro. Atestou que conseguiram abordá-lo e, numa pochete que ele portava, encontraram cocaína, "crack" e R\$ 10,00. Aduziu que ele falou que tinha uma dívida com traficantes e estava traficando para pagar. Acrescentou que não conhecia o acusado anteriormente, mas o local já era bastante conhecido como ponto de tráfico.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar ouvido a fls. 03.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais militares não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Logo, não é razoável supor que policiais atestassem que as drogas estavam na posse do réu, se isso não fosse exatamente o que presenciaram.

Enfim, o fato de os policiais terem apreendido 20 pedras de crack e 86 pinos de cocaína em poder do acusado, o que não foi infirmado por nenhum elemento de prova, conduz à certeza quanto a autoria.

Consigno que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e a forma como estavam acondicionados, aliados ao local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, deixam evidente que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito. Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia.

Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cabendo anotar que, para sua configuração, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente traga consigo a substância entorpecente.

Consigno que não inocenta o réu a alegação de que estaria traficando para pagar dívida que tinha com traficantes, porquanto a ausência de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa reclama, para sua configuração, que o sujeito não possa praticar comportamento diverso do que o vedado por lei, o que não acontece quando alguém se diz impelido a traficar porque alguém determinou que fizesse, pois, ainda que verdadeira a alegação, podia abster-se da prática criminosa.

Sobre o tema o seguinte julgado: Apelação Criminal nº 1525099-29.2019.8.26.0228, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 15.04.20; Apelação Criminal nº 0002812-52.2018.8.26.0400, Rel. Des. Marcelo Gordo, j. 14.04.20 14, e Apelação Criminal nº 1500428-95.2018.8.26.0544, Rel. Des. Claudia Fonseca Fanucchi, j. 12.05.20. 2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que o réu é reincidente (fls. 115/122 e informações da F.A da VEC). Entretanto, esse fato somente pode ser considerado na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se "bis in idem". Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase de fixação da pena, em razão da reincidência (autos 1503841-70.2019 da 2ª Vara Criminal local - cf. certidão de fls. 115/122 e informações da F.A da VEC à fls. 123/128). De outro lado, o réu era menor de vinte e um anos à época dos fatos, razão pela qual mantenho a pena-base fixada.

Inexistem causas de aumento e o acusado não faz jus à redução da pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, em razão da reincidência.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, em razão da reincidência e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII).

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midoila, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, valendo observar que o acusado permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente

é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Porque demonstrada a origem ilícita do dinheiro apreendido, declaro seu perdimento.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de cinco anos de reclusão, e quinhentos dias-multa, no seu valor mínimo legal, fixado o regime inicial fechado e vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que está recolhido e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 23/05/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]